

0002117-63.2017.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... o significado de que toda e qualquer união destinada à prática do tráfico ilícito de drogas caracterize o delito de associação para o mesmo tráfico, pois a união, o acordo de vontades destinado ao cometimento do comércio ilícito, sem a comprovação de uma vontade distinta, organizada no sentido de constituição de uma associação voltada ao mesmo tráfico (vontade, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002117-63.2017.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002117-63.2017.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 34/2009 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Catanduva

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fredson Mendes da Conceição

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

FREDSON MENDES DA CONCEIÇÃO e UELITON ROBERTO DE AGUIAR, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso nos arts. 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque, no dia 18 de abril de 2009, por volta da 1:41 hora, no cruzamento da avenida Palmares com a travessa Angatuba (local conhecido como ponto de venda de drogas), Jardim Nova Catanduva, neste Município e Comarca, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, traziam consigo, para fins de venda a terceiros, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (trinta e duas porções de "crack" e onze de "cocaína"), os quais causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que os acusados estavam associados, de forma permanente e estável, para a prática do delito de tráfico ilícito de drogas.

Consta, também, que os acusados foram presos em flagrante delito no dia dos fatos e

postos em liberdade em data posterior (fls. 60 dos autos principais). Citado e notificado, o acusado Uéliton apresentou a defesa prévia de fls. 106/118 (autos principais). FREDSON, por sua vez, não foi localizado para o ato de citação pessoal, razão pela qual houve citação por edital (fls. 147 - autos principais), após o que o curso do processo e da prescrição ficou suspenso em relação a ele, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal (fls. 154/155 - autos principais). O processo, em relação a FREDSON, seguiu com produção antecipada de provas (fls. 154/155 - autos principais), após a apresentação de defesa prévia em favor de tal acusado (fls. 164/173 - mesmos autos). A denúncia de fls. 2/3 foi recebida em 9 de dezembro de 2013 (fls. 180/182 - autos principais). Durante a instrução criminal inicial, após interrogatório do acusado Uéliton (fls. 263 - autos principais), foram ouvidas três testemunhas de acusação e uma de defesa (fls. 264/265 e 299/301 - autos principais). O feito foi sentenciado inicialmente em relação a Uéliton (fls. 353/355 dos autos principais, cuja cópia encontra-se às fls. 34/37 dos presentes autos desmembrados). O Ministério Público recorreu da r. sentença absolutória prolatada em relação a Uéliton e o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em V. Acórdão de fls. 451/460 dos autos principais, deu provimento ao recurso então interposto pelo órgão ministerial, para condenar referido acusado como incurso no art. 33, "caput", da mesma Lei. Após o sentenciamento do feito em relação a Uéliton, os autos foram desmembrados em relação a FREDSON, dando origem ao processo nº 0002117-63.2017.8.26.0132 (presentes autos). O acusado FREDSON (em face do qual o curso do processo e da prescrição ficou suspenso inicialmente, com fulcro no art. 366, do Código de Processo Penal), foi localizado, citado pessoalmente (fls. 79 destes autos desmembrados), com defesa prévia às fls. 18/28. A suspensão do curso do processo e da prescrição foi revogada (fls. 84 destes autos desmembrados). As partes, nestes autos desmembrados, concordaram com as provas já produzidas no processo principal em sede de produção antecipada de provas (fls. 84, 93 e 95). Em seguida, FREDSON foi interrogado (fls. 118 - autos desmembrados). Nada foi requerido na fase do art. 402, do Código de Processo Penal (fls. 121 e 124 - autos desmembrados). Em seu memorial de fls. 129/133 (autos desmembrados), o Ministério Público pleiteia a procedência parcial da denúncia, justificando que a prova é suficiente para condenar FREDSON apenas como incurso no art. 33, "caput", da mesma Lei. A Defesa, a seu turno, às fls. 137/148 destes autos desmembrados, pugna pela absolvição, alegando, em síntese, insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para a norma prevista no art. 28, "caput", do mesmo Diploma Legal, e ainda alega ocorrência de prescrição.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação, em relação a FREDSON, é parcialmente procedente, pois, conforme adiante será exposto, cometeu tal acusado somente o delito de tráfico ilícito de drogas. A materialidade de tal delito está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 dos autos principais (referente a trinta e duas porções de "crack" e onze de "cocaína" e R\$253,00, em dinheiro) e dos laudos periciais de fls. 20 e 344/345 (autos principais) estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria, quanto ao tráfico ilícito de drogas, também é certa, incontroversa. Ouvido na polícia e interrogado em Juízo (fls. 11 e mídia audiovisual de fls. 268, respectivamente - autos principais), UÉLITON sempre negou a prática da infração penal, dizendo que, pelo fato de usuário de drogas, estava naquele local somente para adquirir a substância, ocasião em que foi abordado e detido pelos agentes da Polícia Militar. Disse que o dinheiro que estava em seu poder era resultante de seu

trabalho (limpeza de terreno) e se destinava à aquisição de drogas e que, assim que chegou ao local dos fatos, um motociclista não identificado ali parou e, ato contínuo, dali se evadiu em razão da presença da viatura policial.

FREDSON, na fase policial (fls. 12 dos autos principais), também negou completamente a prática da infração penal, alegando que não tinha drogas e nem dinheiro em seu poder e que era apenas usuário de "maconha".

Em Juízo (gravação disponível no site do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, consulta processual do 1º Grau, pág. 23 dos autos da carta precatória objeto do processo nº 0003993-73.2019.8.26.0038, conforme se observa a fls. 118 vº destes autos desmembrados), continuou negando a prática do crime, alegando que, cerca de uma semana antes dos fatos narrados nos autos, viu os policiais maltratando um rapaz, motivo pelo qual os xingou. Quanto aos fatos objeto desta ação penal, disse que apenas passava pelo local, para ir buscar sua namorada, ocasião em que foi abordado. O mesmo policial que o interrogando havia visto, em data anterior, maltratando o rapaz, lhe disse que era a oportunidade de "pegar você". Respondeu que só falou o que havia dito em data anterior pelo fato de ter visto o policial maltratando o rapaz. O policial, porém, disse para levar o interrogando preso. Viu os policiais levando Uéliton preso na ocasião. Não estava em companhia de Uéliton. Não estava conversando com um rapaz que estava de motocicleta. Não tinha dinheiro e nem drogas em seu poder. Os policiais levaram um outro rapaz preso na mesma ocasião. Os policiais pularam o muro de uma residência e, em seguida, retornaram com drogas. Não conhece os policiais responsáveis pela ocorrência e nada tem contra eles.

A negativa de autoria, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação.

É que o POLICIAL MILITAR PAULO VÍTOR LARocca, em seu depoimento judicial (mídia de fls. 268 - autos principais), disse não se recordar da presença do acusado Uéliton o local dos fatos e esclareceu, no início do depoimento, que quem deixou a droga cair no chão foi um indivíduo negro que ali estava (acusado Fredson), o qual estava em contato com um motociclista chamado Wagner, este conhecido como chefe do tráfico ilícito de drogas na região em que os fatos ocorreram. No final do depoimento, porém, ficou em dúvida quanto à posse da droga e afirmou que se recordava apenas de que as substâncias estavam no chão.

O POLICIAL MILITAR MARCO ANTONIO DELLA VALLE MORAIS, também em Juízo (mídia de fls. 300 - autos principais), disse ter dado apoio aos demais policiais na ocorrência e que, pelo que ficou sabendo, quem deixou a droga cair no chão foi o indivíduo que se encontrava de motocicleta, o qual se evadiu do local com a chegada da guarnição policial. Acrescentou que foi apreendida droga no local da prisão e que, com um dos indivíduos, foi encontrado dinheiro.

Por último, o TAMBÉM POLICIAL MILITAR OSMAR DONIZETI DOS SANTOS, ouvido em Juízo (mídia de fls. 300 - autos principais), contou que, em apoio aos demais policiais que inicialmente atenderam a ocorrência, apenas apreendeu o dinheiro que um dos indivíduos jogou ao lado de um muro ali existente. Quanto às drogas, relatou que os outros policiais a apreenderam, abandonada.

Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado FREDSON praticava a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia, pois, em ponto de venda de entorpecentes, foi visto, em companhia de Uéliton (já condenado nos presentes autos em sede de recurso de apelação), em local em que foram localizadas inúmeras porções individuais de "crack" e "cocaína", prontas para venda e suficientes, portanto, para fornecimento a inúmeras pessoas, e dinheiro (resultante da venda de drogas, conclusão possível diante das circunstâncias dos autos).

Outro indicativo da ocorrência de prática do comércio ilícito de drogas por parte do acusado é a variedade das substâncias ("cocaína" e "crack"), pela qual se nota que as vendas tinham o objetivo de atingir um número maior de consumidores, usuários de mais de um tipo de droga, os quais, no mesmo local, encontravam substâncias de naturezas diversas; quem negocia drogas de vários tipos visa, obviamente, não perder venda, na medida em que atrai, para um mesmo local, usuários de substâncias de naturezas distintas e, com isso, normalmente alcança um resultado

maior no volume das vendas.

A atitude de FREDSON é típica de quem pratica o comércio ilícito de entorpecentes, pois, se ele, em ponto crítico de venda de drogas, foi encontrado de posse de razoável quantidade de drogas e dinheiro e não apresentou justificativa inequívoca para o encontro das drogas e do dinheiro, é óbvio que ali vendia as substâncias apreendidas em seu poder.

Na situação, inverte-se o ônus da prova, devendo o agente apresentar justificativa convincente para o encontro das várias porções de entorpecentes e dinheiro em sua posse, sob pena de, não o fazendo, responder pelo delito de tráfico ilícito de drogas.

A TESTEMUNHA ELAINE CRISTINA DIAS (mídia de fls. 268 dos autos principais) não presenciou os fatos e seu relato, portanto, não altera o quadro probatório até agora exposto.

Cometeu o acusado FREDSON, assim, o delito que lhe foi imputado na inicial acusatória (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

A negativa de autoria, por outro lado, permaneceu isolada nos autos e, portanto, não merece acolhimento.

Quanto à força probante do probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha.

Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou:

“Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10:138).

“Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT, 668:275).

As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se prontificam a servir como testemunhas aos agentes do Estado.

No que toca à infração penal de associação para o tráfico ilícito de drogas, por outro lado, a prova não é suficiente para a condenação, conforme, aliás, reconheceu o próprio Dr. Promotor de Justiça oficiante em seu memorial de fls. 129/133.

Para a caracterização do delito de associação para o referido tráfico, exige-se que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a prática do crime visado, sendo as vontades, portanto, distintas.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências, trazidas por Renato Marcão em sua obra Tóxicos (São Paulo : Saraiva, 6ª. ed., 2009, p. 256 e 260):

“O delito de associação para o tráfico não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para sua caracterização a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado” [TJSP, Ap. 295.901-3/1-00, 6ª Câmara, j. 6-4-2000, rel. Des. Barbosa Pereira, RT 779/571].

“Configura-se com o animus associativo, isto é, um ajuste prévio, no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdade, em que a vontade de se associar sobrepaire, mas coexista com a vontade necessária à prática do crime visado” [TJSP, Ap. Crim. 210.425-3/7, 4ª Câmara, j. 10-6-1997, rel. Des. Bittencourt Rodrigues, RT 745/539].

“Para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada” [STF, ROHC 75.236-5/AM, 1ª T., j. 3-6-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 1º-8-1997, RT 749/584]” (Tóxicos, São Paulo :

Saraiva, 6ª edição, 2009, p. 256 e 260).

Na mesma linha, leciona Damásio de Jesus:

“Elementos subjetivos do tipo

O primeiro é o dolo, vontade consciente de concretizar a associação. Há um segundo elemento subjetivo do tipo, contido na expressão 'para o fim de praticar' [crimes dos arts. 33, caput e § 1º, 34 e 36 desta Lei]. Sem a finalidade especial o fato é atípico. Nesse sentido: RT 532:381. Assim, a figura típica exige a presença do ânimo associativo, i. e., 'de um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo, uma verdadeira sociedade sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a prática do crime visado' [Vicente Greco Filho, Tóxicos, cit., 1979, p 104]” (Lei Antidrogas Anotada, São Paulo : Saraiva, 9ª ed., revista e atualizada, 2009, p. 160, sem grifos na parte final do texto). A elementar “reiteradamente ou não”, prevista no art. 35, “caput”, não tem o significado de que toda e qualquer união destinada à prática do tráfico ilícito de drogas caracterize o delito de associação para o mesmo tráfico, pois a união, o acordo de vontades destinado ao cometimento do comércio ilícito, sem a comprovação de uma vontade distinta, organizada no sentido de constituição de uma associação voltada ao mesmo tráfico (vontade, no caso, presente na elementar “associarem-se”), caracteriza mero concurso de agentes (CP, art. 29, “caput”) destinado à realização de um dos crimes previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º e 34, ambos de tal Lei, hipótese em que somente um destes (delitos previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º, e 34) se consuma; e, para a caracterização da infração penal de associação para o tráfico, exige-se, consoante já exposto, um dolo distinto, separado do cometimento em si do tráfico ilícito de drogas, ainda que não haja reiteração de conduta, sendo este o significado da primeira elementar ora mencionada (“reiteradamente ou não”). São situações distintas, portanto, sendo o ato de se associar para o tráfico, o qual exige prova concreta (separada), uma coisa, e o de praticar efetivamente o tráfico ilícito, outra; caso dois ou mais agentes, por exemplo, atuem em conjunto para vender drogas, sem a constituição de uma associação destinada ao comércio ilícito, ocorre mero concurso de agentes para o cometimento do crime previsto no art. 33, “caput”, e, na hipótese de além de a venda em si da substância ilícita, eles estabelecerem um vínculo associativo, organizado, distinto, destinado às vendas, a conduta criminosa descrita no art. 35, “caput”, também se caracteriza. Aliás, sendo o momento consumativo do crime de associação para o tráfico a ocasião em que os agentes se associam para a prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º, e 34, ambos de tal Lei (conforme lição de Damásio de Jesus sobredita), o crime previsto no art. 35, “caput”, do mesmo Diploma Legal, pode ocorrer sem que o agente pratique efetivamente os crimes descritos nos dispositivos de lei supramencionados (arts. 33, “caput” e § 1º, e 34).

Quanto ao momento consumativo do crime, ensina Damásio de Jesus:

“Momento consumativo

Ocorre com a associação. Na expressão de Italo Galli, no 'momento associativo' [JTACrimSP, 54:351]. Nesse sentido: RT, 634:277; RJTJSP, 72:316; STJ, REsp 3.943, 5ª. Turma, DJU, 5 nov. 1990, p. 12437, independentemente de eventual prática dos crimes pretendidos pelo bando. Nesse sentido: RJTJSP, 69:348. Sob esse aspecto, trata-se de crime formal ou de consumação antecipada, natureza extraída do elemento subjetivo do tipo 'para o fim de...'. Nesse sentido: RJTJSP, 69:348” (op. cit., p. 161/2).

No caso presente, no entanto, não ficou comprovada a existência de uma vontade distinta, por parte do acusado, no sentido de constituição de uma associação (é dizer, de um vínculo associativo) direcionada à prática do delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto as diligências policiais limitaram-se ao momento dos fatos e ao dia da prisão e, pelos depoimentos dos policiais, referido vínculo associativo não ficou, portanto, provado.

Para a comprovação do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, são necessários elementos concretos de prova no sentido de existência do referido vínculo (associativo) entre os agentes, tais como interceptações telefônicas anteriores ou em andamento, pedidos de busca e apreensão anterior, realizações de campanhas em datas anteriores, apreensão de eventual documentação comprobatória e

até mesmo apreensão, em data anterior, de drogas pertencentes aos investigados, não bastando, desse modo, meras informações genéricas e anônimas dando conta de que os mesmos agentes/investigados vinham praticando a mercancia ilícita.

Ademais a doutrina e a jurisprudência, quase que de forma unânime, exigem a comprovação de dois requisitos para a caracterização de delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, sendo eles estabilidade e permanência, os quais não ficaram comprovados na conduta do acusado.

Sobre a necessidade de prova de tais requisitos (estabilidade e permanência) na espécie, segue o posicionamento da jurisprudência:

"Apelações do Ministério Público e de um dos réus - Tráfico de entorpecente e associação para tal delito. Insurgência ministerial que se restringe à absolvição dos réus da associação - Ausência de estabilidade e de ânimo subjetivo - Precedentes - Absolvição que se mantém. Defesa que busca a absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal ou redução das penas - Acusados apanhados com 18 pinos de cocaína (11,23g) - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Desclassificação para uso pessoal - Impossibilidade - Finalidade mercantil - Pena mínima reduzida de 1/6, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conformada a acusação nesse ponto - Regime fechado - Necessidade. Recursos não providos" (TJ-SP - APL: 00000565820148260417 SP 0000056-58.2014.8.26.0417, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2015).

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉUS QUE TRANSPORTAVAM E GUARDAVAM 11 PORÇÕES DE MACONHA, PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE FABRICAÇÃO, PRODUÇÃO, PREPARO OU TRANSFORMAÇÃO DE ENTORPECENTES - CONDUTAS NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS - OBJETOS APREENDIDOS QUE SE DESTINAVAM À SEPARAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DOS TÓXICOS - ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 34 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO REDUTOR, PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS PARA O RÉU NIVALDO - POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJ-SP - APL: 30038922720138260286 SP 3003892-27.2013.8.26.0286, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 29/10/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/11/2015).

No mesmo sentido, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

"101. Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos no arts. 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Demanda-se a prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa. Nesse prisma: STJ: 'O crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06 exige que a associação entre os agentes ocorra de forma estável ou em caráter permanente, caracterizando a reunião eventual mero concurso de pessoas. No caso, tendo as instâncias ordinárias, após exame das provas dos autos, constatado a existência de estabilidade e permanência entre o agravante e outros indivíduos, inviável a reversão do julgado ante o óbice constante da Súmula 7/STJ.' [AgRg no AREsp 303.213/SP, 5.ª T, rel. Marco Aurélio Bellizze, DJ 08.10.2013]; 'O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos art. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. II- De outro lado, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para a sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006.' [REsp 1.113.728-SC, 5.ª T., rel. Felix Fischer, 29.09.2009, v.u.]. TJDF: 'O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da

Lei n.º 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1.º, e artigo 34 do mesmo diploma legal. assim, diante das provas do animus associativo de caráter estável e duradouro entre o apelante e os codenunciados, inviável o pleito absolutório quanto ao delito de associação para o tráfico, especialmente pelas declarações prestadas pelos policiais, corroboradas pelas interceptações telefônicas.' [Apelação 20100112165299APR, 2.ª Turma Criminal, rel. Roberval Casemiro Belinati, DJ 20.03.2014]. TJSP: 'Acusados que se cooperavam, agindo mutuamente, ainda que eventualmente, na prática do comércio de entorpecentes. Insuficiência de provas - Acolhimento Não configurada a estabilidade e permanência do vínculo subjetivo. Absolvição que se impõe. Recursos defensivos providos.' [Apelação 0029273-41.2010.8.26.0562, 4.ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. César Augusto Andrade de Castro, DJ 27.03.2014]. TJMG: 'A atuação das rés em ´societas sceleris´, realizando, de forma estável e permanente, um programa delinquencial e praticando crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente da droga denominada cocaína, dá ensejo à condenação pelo delito tipificado no art. 14 da Lei 6.368/76 [revogada].' [Ap. 1.0324.03.016270-9, rel. Paulo César Dias, 23.11.2004, DJ 25.02.2005]..." (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol. 1, Rio de Janeiro : GEN/Forense, 8.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 361/2). Dessa forma, quanto ao tal ponto da acusação, deve militar, em favor do acusado, o princípio "in dubio pro reo", pelo qual a dúvida favorece o agente. O decreto condenatório, somente quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas, pois, é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mínima legal.

Observo que, ainda que de alto poder lesivo, a droga é de pouca quantidade, situação em que não se justifica ao aumento da pena nesta fase.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, tendo em vista que o acusado não registra antecedentes e não havendo comprovação de que ele viesse se dedicando às atividades criminosas ou integrando organização criminosa, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O acusado não era conhecido nos meios policiais (depoimentos dos policiais), a droga apreendida não era de expressiva quantidade e a quantia em dinheiro localizada era de baixo valor, caso em que não pode ser descartada a hipótese de ele ser mero traficante ocasional, não havendo comprovação, portanto, de eventual dedicação às atividades criminosas.

Não há provas no sentido de que o acusado integrasse organização criminosa ou se dedicasse às atividades criminosas, vez que não ficou esclarecido, por exemplo, qual a organização criminosa que eventualmente atuava no local dos fatos, quem a integrava, quais as divisões de tarefas e qual eventual participação do imputado nela, não havendo, portanto, prova segura e conclusiva a respeito, situação em que deve ser aplicado, em favor do agente, o princípio "in dubio pro reo".

Abonando tal entendimento:

"O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organizações criminosas deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução de pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo (STF, HC 103225 - RN, 2ª T., rel. Joaquim Barbosa, 11.10.2011, v.u., julgado citado por Guilherme de Souza Nucci em Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - volume 1, Forense : Rio de Janeiro, 8ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 349).

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser

pessoa de baixa condição financeira - interrogatório judicial e informações sobre a vida pregressa de fls. 36 dos autos principais).

Diante do novo posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal (HC nº 118.533, Plenário do STF, j. em 23/06/2016), acolhido, aliás, pela denominada Lei Anticrime (art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal, com redação dada por tal Lei - Anticrime), o crime de tráfico na forma privilegiada, hipótese tratada nos autos, deixou de ser equiparado a hediondo, razão pela qual, não havendo impedimento legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (CP, art. 3, § 2º, "c").

Também não havendo impedimento legal, substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena corporal, cujo local e forma de cumprimento serão fixados na fase de execução, e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal), compatíveis diante da conduta objeto destes autos.

A respeito da possibilidade de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos em casos de tráfico privilegiado, trago à cola o seguinte Julgado:

"Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, para fornecimento a consumo de terceiros, 34 porções de maconha, com peso bruto de 53,3 gramas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante delito. Depoimento dos policiais. Apreensão da droga. Negativa isolada nos autos. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade de entorpecente e das circunstâncias judiciais favoráveis do agente. Não comprovação de que o réu se dedica a atividades criminosas. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa. SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esses fins" (TJSP, Apelação Criminal nº 0002334-14.2014.8.26.1032, Comarca de Catanduva, 16ª Câmara Criminal, Rel. Otávio de Almeida Toledo, j. em 14/02/2017, v.u.).

No mesmo sentido (possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direito) também já foi decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no "Habeas Corpus" nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, j. em 08/09/2020, Sexta Turma.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública contra FREDSON MENDES DA CONCEIÇÃO, nos autos qualificado, para o fim de: a)- CONDENÁ-LO como incurso no art. 33, § 4º, da Lei, nº 11.343/2006, c/c o art. 29, "caput", do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção já mencionada, na proporção já mencionada, substituída, no entanto (somente a pena corporal), pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a um salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal); e b)- ABSOLVÊ-LO da imputação do art. 35, "caput", da mesma Lei, absolvição que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Condeno o acusado FREDSON, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil.

Havendo descumprimento injustificado das penas restritivas de direitos ora fixadas, serão elas convertidas em privativa de liberdade (no caso a inicialmente estabelecida nesta sentença).

Quanto à destinação das drogas e do dinheiro apreendido já houve deliberação na sentença prolatada em face de Uéliton (fls. 355 dos autos principais).

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive, se o caso, à Justiça Eleitoral.

Fica rejeitada a alegação de prescrição, pois o lapso prescricional previsto para a espécie, de 4 (quatro) anos, ainda não foi superado até a presente data; a prescrição correu desde a data do recebimento da denúncia (09/12/2013 - fls. 180/182 dos autos principais) e, após suspensão de seu curso desde 22 de abril de 2013 (fls. 154/155 - autos principais) até 17 de janeiro de 2019 (fls. 80 destes autos desmembrados), voltou a correr novamente, de tal sorte que o lapso prescricional de 4 (quatro) anos não foi superado até a presente data. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). P. I.C.
Catanduva, 27 de junho de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA